

1502683-62.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... CRIMINAL - Receptações e tráfico de drogas - Recurso defensivo - Preliminar de violação ao princípio do juiz natural - Inocorrência - Designação prévia, dos magistrados, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça - Preliminar de nulidade ab initio, por violação a domicílio - Entrada franqueada - Tráfico de drogas - Delito permanente - Se aos policiais não foi dado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502683-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502683-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029220/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 22764854 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 298/22/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2029220 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE PAULA MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

FERNANDO DE PAULA MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Paim, nº 211, Bela Vista, nessa cidade e comarca de São Paulo/SP, mantinha em depósito 22,4 gramas de metilenodioximetanfetamina, popularmente conhecida como ecstasy, acondicionada em 80 invólucros; e 29,6 gramas de cocaína, acondicionada em 32 invólucros plásticos, sendo certo que referidas substâncias são causadoras de

dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 59/63).

A denúncia foi recebida (fls. 122/123). O réu foi citado (fls.). Houve apresentação de resposta à acusação (fls 143/147), sendo ratificação o recebimento da denúncia em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidos quatro testemunhas e um declarante, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público refutou a preliminar arguida na defesa prévia e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, alegou, em suma, que o flagrante foi forjado, requerendo a absolvição por força do princípio in dubio pro reo. Requereu, ainda direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao réu a conduta típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitativa foi demonstrada por meio dos autos de exibição/apreensão de fl. 13/14 e 28/29, do laudo de constatação de fl. 37/40, do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 128/130 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório que também comorou a autoria.

O réu negou a prática do delito. Afirmou, em suma, que estava saindo do prédio com Maycon, quando o policial José Carlos chegou e disse "perdeu", algemando-o. O policial Edvan pediu cinquenta mil reais, em espécie, em troca de não prendê-lo, Perguntaram se lembravam dele. Entraram em sua casa, mas não autorizou a entrada porque já estavam dizendo que "perdeu". Ligou para sua mãe, pedindo dez mil, mas ela não tinha. Afirmou que os policiais queriam agredir seu cachorro e zombaram de suas roupas. Acredita que não havia motoboy no local. Entraram entre quatro e cinco policiais em sua casa e nada foi encontrado. Não sabe de onde saiu a droga que apresentaram na delegacia. Acredita que o porteiro não tenha visto a abordagem. Não prestava nenhum serviço via aplicativo. Disse já ter feito uso de drogas. Não conhece Paulo Henrique Jesus Souza. Negou ser traficante. Relatou que já havia sido preso pelos mesmos policiais e que já havia ouvido que policiais vão atrás depois em busca de dinheiro, mas não havia nenhuma desavença cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial civil Edvan Arlindo Duarte narrou, em suma, que obtiveram informações de que na rua descrita na denúncia, uma pessoa chamada Fernando estaria entregando drogas por sistema "delivery". Passaram também as características do Fernando.

Foram ao local, onde avistaram Paulo, em uma moto. Em seguida, o réu saiu do prédio e entregou ao motociclista um envelope. Abordado Paulo, com ele nada encontraram. O réu já fora preso em 2020. Perguntaram ao réu onde estava a droga, tendo ele dito que não tinha. Pediram para irem até seu apartamento, mas ele os levou em outra casa. Disseram que sabiam que não era o apartamento dele. Na sua casa, numa gaveta do guarda roupa, encontraram 80 comprimidos de ecstasy, 32 porções de cocaína, além de uma pequena quantidade de dinheiro. Afirmou nada ter contra o réu. O acusado disse que as drogas eram para seu uso pessoal. Paulo chegou a mencionar que fez uma entrega para o réu, mas disse não saber qual o conteúdo (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A testemunha José Carlos Cardoso, policial civil, afirmou, em suma, que um indivíduo estava traficando no endereço mencionado na denúncia, por meio de aplicativos de entrega. No local, fizeram campana e viram um motoboy chegando no local, sendo que o réu foi até seu encontro. Abordados, com o motoboy nada foi encontrado de ilícito. O réu negou que estivesse traficando. Pediram para irem até seu apartamento, tendo ele concordado. Todavia, tentou levá-los a apartamento

diverso, mas disseram que sabiam qual era o número. Não se lembra quais as drogas foram encontradas, nem se encontraram dinheiro também. O réu confessou para o depoente que estava traficando. As denúncias recebidas já indicavam as características do acusado e seu endereço. O réu autorizou a entrada em seu apartamento. O réu estava com o motoboy no momento da abordagem. Acredita que o motoboy tenha ido até o apartamento também. Quando receberam as informações, não sabia de que se tratava. Depois reconheceu o réu, pois já o prendera em 2020. Não há nenhuma desavença entre eles (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Maycon Vinagre afirmou, em suma, ser amigo do acusado. Disse que desceram para irem até o mercado. Quando voltaram, policiais subiram contra a vontade do réu. Foi posto para fora do apartamento. Disse que não havia nada no apartamento, pois estava lá antes e ajudou a fazer mudança. Fazia um mês que ocorrera a mudança. Não sabe se o acusado faz uso de drogas. Presenciou a abordagem feita pelos policiais. Disse que os policiais foram ríspidos e chegaram a perguntar se o réu tinha dinheiro. Conhece o réu desde 2019 e frequentava sua casa. Disse que o acusado fazia bicos. Não viu motoboy. No local, havia porteiro. Não sabe se o réu já conhecia os policiais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Jennifer Beatriz Taconi Moreira, sobrinha do acusado, disse, em suma, que foi informada acerca da prisão do réu. Afirmou que o acusado não trafica, bem como que ele já teve passagem, mas era inocente. Afirmou que ao acusado era autônomo. A família tem boa relação como réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Washington Henrique de Paula Moreira, irmão do acusado, disse ter ficado sabendo da prisão do réu por meio do advogado. Afirmou que nunca soube que o réu seja traficante, tendo sido uma surpresa o ocorrido. Disse que o réu já trabalhou com ele, inclusive recentemente. Acha que seu irmão não usa drogas e pelo que sabem nunca tinha sido preso (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Não há, nos autos, contraprova a desacreditar os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Jennifer e Washington nada disseram sobre os fatos, ao passo que Maycoin declarou que não ficou no interior do apartamento quando das buscas policiais. E não há como a testemunha afirmar que nada havia no local, esclarecendo, após ser indagada se abrisa as gavetas, que ajudara na mudança há um mês atrás. Referida informação não esclarece o que o houve no período posterior, pois os policiais relataram que encontraram a droga dentro da gaveta do guarda-roupa.

Demais disso, na delegacia, Paulo Henrique Jesus Souza declarou, em resumo, que trabalhava em sua motocicleta marca Honda, placas FAF-0860, como entregador de aplicativos, entre os quais LALAMOVE, instante em que atendeu ordem de serviço com quatro paradas, ou seja, pegar dois envelopes com o réu, na Rua Paim, 211 e entregar um na Rua Dr Cesário Mota Junior, 524; depois entregar o outro na Rua General Flores, 166; pegar uma chave na Rua Jaguaribe, 373 e retornar na Rua Paim, onde terminaria o serviço entregando ao acusado a chave em questão. Afirmou que quando iria entregar a chave ao réu, chegaram policiais civis, que os interpelaram. Em seguida, os policiais foram ao apto do réu, que tentou levá-los em outro local, mas eles sabiam onde o referido residia. Afirmou que os policiais encontraram, dentro de um guarda-roupas, papetes de substância de branca e comprimidos. Declarou, ainda, não ter ouvido o réu confessar que traficava drogas (fls. 11). Destarte, prevalecem os testemunhos por prestados pelos policiais, que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, possuindo força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, negando a propriedade da droga encontrada, além de não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo

para lhe incriminar falsamente, os depoimentos prestados pelos policiais foram confirmados, durante o inquérito policial, pelo motoboy por ele mencionados. Ademais, há que destacar que não se vislumbra ilicitude na prova obtida com a busca e apreensão do entorpecente realizada na residência em questão, pois pelo que consta dos autos, o réu franqueou a entrada dos policiais em sua casa, o que, aliás, restou confirmado pela defesa às fls. 89/90.

Ademais, a Constituição Federal no artigo 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, mas ressalva o ingresso, sem consentimento do morador, em caso de flagrante delito. Assim, observados os requisitos constitucionais, diante o flagrante de crime de tráfico no caso em tela, crime este de natureza permanente. No caso em apreço, pelo que se depreende dos autos, os policiais civis receberam informações de que uma pessoa chamada "Fernando" estava traficando por meio de aplicativo de entrega e, no local que lhe fora informado viram o acusado em contato com um motoboy. Assim, presentes justa causa e urgência para o ingresso dos policiais no interior da residência, onde, aliás, encontraram expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptações e tráfico de drogas - Recurso defensivo - Preliminar de violação ao princípio do juiz natural - Inocorrência - Designação prévia, dos magistrados, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça - Preliminar de nulidade ab initio, por violação a domicílio - Entrada franqueada - Tráfico de drogas - Delito permanente - Se aos policiais não foi dado o ingresso à residência, havia permissão constitucional para a penetração, porquanto o delito permanente tem sua consumação protraída no tempo - Preliminares afastadas - No mérito, materialidades e autorias todas comprovadas - Ciência da origem ilícita dos bens que se comprova pela atitude e natureza da res - Tráfico mais que evidenciado - Elevadíssima quantidade de entorpecente, com petrechos para venda - Pena não modificada, para o tráfico, em virtude de erroneamente se ter aplicado a causa de diminuição especial, para indivíduo dedicado às atividades criminosas - Preliminares afastadas e recursos não providos. (TJ-SP - APL: 00442611420148260114 SP 0044261-14.2014.8.26.0114, Relator: Alberto Anderson Filho, Data de Julgamento: 28/07/2016, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/08/2016) (grifo nosso)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório - Apreensão de considerável quantidade de droga (03 tijolos de maconha, com peso líquido de 684,60 gramas), além de dinheiro e uma balança de precisão - Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares. Quantidade e natureza do entorpecente e mau antecedente (1/6) - Compensação da agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública) com a atenuante da confissão espontânea. Reincidência específica (1/6) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) - Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei - Prequestionamento - Apelo desprovido (TJ-SP - APR: 15018282120208260530 SP 1501828-21.2020.8.26.0530, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 23/04/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica, no caso em tela, desrespeito ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria, fixou tese nos seguintes termos:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,

que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, “manter em depósito” 80 invólucros de ecstasy e trinta e duas porções de cocaína

Destarte, os depoimentos colhidos, e não só a quantidade de droga, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar o pedido formulado pela a Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecente, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravante e atenuantes. Desse modo, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, verifica-se que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional. Embora o acusado seja primário, é de se considerar que responde a outro processo por tráfico (fls. 41/42) e o policiais receberam informações de que ele vinha traficado por meio de aplicativo de entregas. Assim, evidente que seu envolvimento com o tráfico não foi um fato isolado. Destarte, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela, mantendo a pena no patamar fixado.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º do CP). Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu FERNANDO DE PAULA MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em

seu valor mínimo legal.

Ausente o requisito temporal para detração, nos termos do artigo 112, inciso II, da Lei 7.210/84.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade do caso concreto, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além do fato de responder a outro processo por fatos análogos, o que revela que a prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública. Ademais, não se consta a ilegalidade da prisão alegada em defesa preliminar. Recomende-se no cárcere em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Por fim, diante da narrativa do acusado de que os agentes policiais quiseram agredir seu cachorro e zombaram de suas roupas, encaminhe-se cópia do interrogatório judicial a Corregedoria da Polícia Militar para as providências necessárias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA